

Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC

Valor probatorio del testigo único/ ilicitud sustancial

DEL VALOR PROBATORIO DEL TESTIGO ÚNICO

"Sea procedente indicar que nuestro sistema jurídico, en lo concerniente al aspecto probatorio, ha sobrepasado la noción de tarifa legal que lo permeaba en pretéritas épocas, asumiendo el legislador un sistema menos formalista y que fue reemplazado por otro basado en el pleno reconocimiento de las reglas de la lógica, la experiencia y la ciencia.

Este sistema de valoración que impera en el derecho penal, como en el disciplinario y que se denomina en lo que se conoce como "sana crítica", se encuentra inserto en un contexto en el que no se privilegia una tarifa o valor predeterminado de una prueba, ni el aporte cuantitativo de varias, sino al análisis razonable y coherente de una situación a través de las reglas arriba referidas, por lo que resulta procedente conceder valor al testigo único como una fuente viable y legítima de convicción, atendiendo el contexto ponderado de sus planteamientos y las características o particularidades inherentes a la forma en que dicho testigo tuvo contacto con la situación o hecho objeto de la investigación".

TESTIGO ÚNICO/ SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

La jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha avanzado en el tema del testigo único como fuente y soporte de una decisión. Al respecto ha señalado:

"...a pesar del histórico origen vivencial o práctico de la regla testis unus, testis nullus, hoy no se tiene como máxima de la experiencia, por lo menos en sistemas de valoración racional de la prueba como el que rige en Colombia (C. P. P., arts. 254 y 294), precisamente porque su rigidez vincula el método de evaluación probatoria a la anticipación de una frustración de resultados en la investigación del delito, sin permitir ningún esfuerzo racional del juzgador, que además es contraria a la realidad (más en sentido material que convencional) de que uno o varios testimonios pueden ser suficientes para conducir a la certeza. Todo ello desestimularía la acción penal y se opone a la realidad de que en muchos casos el declarante puede ser real o virtualmente testigo único e inclusive serlo la propia víctima.

No se trata de que inexorablemente deba existir pluralidad de testimonios o de pruebas para poderlas confrontar unas con otras, única manera aparente de llegar a una conclusión fiable por la concordancia de aseveraciones o de hechos suministrados por testigos independientes, salvo el acuerdo dañado para declarar en el mismo sentido. No, en el caso del testimonio único lo más importante, desde el punto de vista legal y razonable, es que existan y se pongan a funcionar los referentes empíricos y lógicos dispuestos en el artículo 294 del Código de Procedimiento Penal, que no necesariamente emergen de otras pruebas, tales como la naturaleza del objeto percibido, la sanidad

de los sentidos por medio de los cuales se captaron los hechos, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió, la personalidad del declarante, la forma como hubiere declarado y otras singularidades detectadas en el testimonio, datos que ordinariamente se suministran por el mismo deponente y, por ende, dan lugar a una suerte de control interno y no necesariamente externo de la prueba.

Con una operación rigurosa de control interno de la única prueba (aunque sería deseable la posibilidad de control externo que pueda propiciar la pluralidad probatoria), como la que ordena singularmente la ley respecto de cada testimonio o medio de prueba (art. 254, inciso 2º C. P. P.), también es factible llegar a una conclusión de verosimilitud, racionalidad y consistencia de la respectiva prueba o todo lo contrario. Ciertamente, la valoración individual es un paso previo a la evaluación conjunta, supuesto eso sí el caso de pluralidad de pruebas, pero ello que sería una obligación frente a la realidad de la existencia de multiplicidad de medios de convicción, no por lo mismo condiciona el camino a la adquisición de la certeza posible aún con la prueba única”.¹

Dependencia:	Subdirección de Investigaciones Disciplinarias
Número del Proceso:	1704-01-2014-336
Número y fecha del fallo:	RESOLUCIÓN No. 17317-00001 del 06 de febrero de 2018
Asunto:	Fallo de Primera Instancia
Criterio de Selección:	Declarar la Responsabilidad Disciplinaria

RESOLUCIÓN No. 17317-00001 del 06 de febrero de 2018

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-336

1. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Concluida la investigación disciplinaria tramitada en el proceso administrativo disciplinario número **1704-01-2014-336**, el Subdirector de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales ITRC, procede a continuación a proferir fallo de primera instancia, conforme a las exigencias del artículo 170 de la Ley 734 de 2002.

2. IDENTIDAD DEL INVESTIGADO

XXXXX, identificado con C.C. 91.207.591, quien para la fecha de los hechos se desempeñaba en el cargo de ANALISTA I CODIGO 201 GRADO 01 ubicado en el GIT de la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga.

3. HECHOS

Fueron relatados tal y como obra en el pliego de cargos de la manera que sigue:

“ El día 9 de diciembre de 2014, cerca de las 3:00 p.m., el señor xxxxx, se presentó en las instalaciones de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, con el fin de radicar el oficio remitido por la Notaria 7ª de esa ciudad, mediante el cual se informaba que se había autorizado la sucesión del señor xxxxx, padre del señor xxxxx, a través de este se requería la expedición de un paz y salvo en favor del señor Pimiento Sarmiento para el trámite sucesoral, el mentado oficio fue recibido por el señor xxxxx funcionario del Grupo Interno de Trabajo de la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la Seccional de Bucaramanga, quien de manera

¹ CSJ, Sala de Casación Penal MP. JORGE ANIBAL GOMEZ GALLEG0. PROCESO 13119, DICIEMBRE 15 de 2000

indebida y aprovechando su calidad de funcionario, le solicitó al señor xxxxx la suma de cuatrocientos mil pesos (\$400.000) con el objeto de expedirle de manera más expedita la certificación requerida por la Notaría”.

4. CARGO FORMULADO

Por medio del Auto No. 1740600012 del 30 de mayo de 2017, la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la UAE ITRC, formuló pliego de cargos al investigado xxxxx. El cargo disciplinario formulado se redactó textualmente en la siguiente forma:

CARGO ÚNICO

“El señor xxxxx, en su condición de funcionario del Grupo Interno de trabajo de la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de Bucaramanga, ocupando el cargo de Analista I Código 201 Grado 01, al parecer incurrió en la conducta descrita en la Ley 734 de 2002, artículo 48 numeral 1º, en armonía con el artículo 404 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), por cuanto el día 9 de diciembre de 2014, cerca de las 3:00 p.m., en las instalaciones donde labora, abusó de su cargo o función como servidor público, al realizar una solicitud indebida de dinero específicamente la suma de cuatrocientos mil pesos (\$400.000), al señor xxxxx, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.245.025, con el objeto de expedirle de manera más expedita un certificado de paz y salvo requerida dentro de la sucesión de su padre el señor xxxxx adelantada en la Notaría 7º del círculo de Bucaramanga”.

5. ARGUMENTOS DE DEFENSA:

VERSIÓN LIBRE, DESCARGOS Y ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Los argumentos de defensa se han basado en los siguientes aspectos:

Para el disciplinado, no existe prueba que comprometa su responsabilidad, ya que existe la versión del usuario sobre una situación que no sucedió, ni se encuentra demostrada. Para el efecto argumenta que todos los testimonios y las pruebas documentales recolectados en la investigación tuvieron como origen la reunión organizada por el Director Seccional, mediante la cual pretendió obtener una confesión de su parte, incurriendo en un constreñimiento ilícito y en contravía de los derechos y garantías fundamentales, por lo que tal fundamento probatorio era nulo. Consecuencia de ello solicitó que no se tuviera en cuenta el informe producto de dicha reunión, además que los testigos presentes en la misma son, respecto de los hechos objeto de investigación, testigos de oídas.

Cuestionó los testimonios de xxxxx y xxxxx, al considerar que no aportaron elementos demostrativos de su responsabilidad en los hechos, aunque si plantearon la existencia de instrucciones que el Director Seccional efectuara a la última, para que directamente asumiera el trámite para la rápida expedición del certificado requerido por xxxxx, sin reparar en la existencia de una investigación de fiscalización en la que el causante estaba involucrado por una presunta omisión que ascendió a \$ 33.931.313, lo que demostraría que xxxxx logró en tiempo muy breve la certificación, con sólo acudir al Director para enrostrarle un hecho que no había realizado con la certeza de que su estrategia daría los frutos esperados.

Con fundamento en lo anterior considera que la confesión obtenida de su parte fue obtenida con una clara violación a sus derechos siendo claro que es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación al debido proceso, por lo que solicita se de aplicación a la regla de exclusión que tiene dos grandes fuentes jurídicas, la prueba inconstitucional y la prueba ilícita, esta última que se aplica al caso en concreto, pues considera que todo se originó con la indebida actuación del señor

Director, luego de citarlo, estando en uso de permiso sindical, a inculparlo de un hecho al que le dio credibilidad ejerciendo una indebida presión no solo de su parte si no a través de cuatro abogados que le insistían en que dijera la verdad.

Finalmente, pese al traslado para alegar de conclusión, ni el investigado, ni su defensor, hicieron uso de su derecho a presentar alegatos de conclusión.

6. CONSIDERACIONES DE INSTANCIA:

RAZONES DE LA DECISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS EN QUE SE BASA

6.1. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA:

Este Despacho es competente para proferir el fallo de primera instancia dentro de la presente investigación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con las previsiones del Decreto 4173 del 3 de noviembre de 2011.

De otra parte, y siendo el Despacho consecuente con lo ordenado en el Artículo 142 de la Ley 734 de 2002, estudiará la procedencia o no del fallo sancionatorio, teniendo en cuenta que debe existir en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado, y cuya apreciación debe corresponder a las reglas de la sana crítica, según lo establece el Artículo 141 de la normatividad.

De igual manera, deben reunirse de manera conjunta los requisitos de legalidad, ilicitud sustancial y culpabilidad, reglados en los artículos 4, 5 y 13 de la Ley 734 de 2002, los cuales es menester se encuentren debidamente acreditados dentro del sumario a partir de elementos de prueba legalmente allegados al proceso.

6.2. DE LAS PRUEBAS FUNDAMENTO DE LA DECISIÓN

En primer lugar, es oportuno resaltar que el material probatorio fue allegado al expediente en legal y debida forma, por lo que se procederá a relacionar y examinar los elementos incorporados en aras de verificar la ocurrencia de la conducta presuntamente irregular, así:

6.2.1. Documentales

6.2.1.1. Oficio 100206214 de 22 de enero de 2015 (folios 58 y 59), por medio del cual la funcionaria XXXXX -Subdirectora de Gestión de Personal- de la DIAN, remitió certificación laboral del investigado XXXXX, así como también informó que su dirección es la calle 97 No. 14 A -14 Casa - Ciudad Venecia Bucaramanga – Santander, la cual se obtuvo de la última declaración juramentada de bienes y rentas del 27 de marzo de 2014.

6.2.1.2. Correo electrónico de fecha 12 de febrero de 2015 (folios 94 a 96), por medio del cual el funcionario XXXXX de la Coordinación de Historias Laborales de la Subdirección de Gestión de Personal de la DIAN, remitió el último comunicado de funciones del funcionario XXXXX y en el que hace la salvedad que una vez verificado el sistema de Recursos Humanos y Nomina KACTUS – HR se encontró que el funcionario referido se encuentra ubicado desde el 17 de diciembre de 2014 en el G.I.T DE DOCUMENTACION – DIVISION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA –DIAN BUCARAMANGA-.

6.2.1.3. Oficio 1-04-242-448-2201 de 18 de Febrero de 2015 (folio 112), mediante el cual la servidora pública XXXXX del Grupo de Gestión de Cobranzas de la División de Gestión de Cobranza

de la Seccional de Bucaramanga, informó que entre el 15 de febrero de 2011 hasta el 14 de diciembre de 2014 y entre el 1 de diciembre y hasta el 15 de Diciembre del año 2014, el servidor público XXXXX, gestionó 176 certificaciones de sucesiones y recibió 168 solicitudes entre sucesiones y liquidaciones voluntarias de sociedades, junto con las certificaciones de nivel nacional que no son cuantificables, lo cual permitió concluir que el investigado tenía una carga laboral total de 344 solicitudes de certificaciones.

6.2.1.4. Diligencia de inspección administrativa realizada el 13 de marzo de 2015 (folios 126 a 136), al expediente adelantado por la DIAN – Bucaramanga, relacionado con la sucesión del causante XXXXX en la cual fungió como apoderado XXXXX. Con el objeto de verificar todas las actuaciones surtidas por el investigado, dicha diligencia fue atendida por la Jefe del GIT de Gestión Cobranzas de esa seccional, XXXXX, quien puso a disposición los documentos con radicado de entrada 023611 así:

-Oficio de fecha 4 de diciembre de 2014 (folio127), suscrito por Blanca Lucia Ramírez Dueñas Notaria Séptima (E) del Circulo de Bucaramanga, con sello recibido de la DIAN de fecha 9 de diciembre 2014, radicado “023611 9 PM 3:05”.

- Copia de Declaración de Renta y Complementarios del señor XXXXX identificado con NIT XXXXX del año 2013 (folio 128), con fecha 11 diciembre de 2014.

- Oficio 1-04-238-416-28-0034 fechado 27 de enero de 2015 (folio 129), suscrito por XXXXX –Jefe del GIT de Auditoria Tributaria I, de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, mediante el cual informan que revisada la exógena y los sistemas institucionales disponibles en la fecha y dentro de la revisión preliminar al proceso de sucesión del señor XXXXX identificado con NIT XXXXX en cuantía de \$ 843.469.696, se detectaron inconsistencias estableciendo una presunta omisión de activos y de ingresos, frente a los declarados en renta año gravable 2013 así:

	DECLARADOS EN RENTA 2013	REPORTADOS POR TERCEROS EN EXÓGENO	VALOR SUCESIÓN	DIFERENCIA ESTABLECIDA COMO POSIBLE OMISIÓN
PATRIMONIO	817.357.000	802.582.704	843.469.696	26.112.696
INGRESOS	12.071.000	19.889.817		7.818.817
			TOTAL, PRESUNTA OMISION	33.931.513

Dicho oficio tiene como anexos las declaraciones de renta y complementarios de los años 2012 y 2013 junto con el cuadro que detalla la consulta realizada a la cedula XXXXX (folio 130 a 133).

- Oficio No. 1-04-242-448-8882 de fecha 12 de diciembre de 2014 (folio 134), dirigido a la Notaria Séptima del círculo de Bucaramanga, mediante el cual el jefe GIT Gestión Cobranzas XXXXX, informó que el causante XXXXX C.C. No. XXXXX, no tiene a la fecha obligaciones fiscales pendientes de pago en esa Dirección Seccional, ni existe a su nombre en trámite proceso de determinación o discusión del tributo.

6.2.1.5. Oficio de fecha 8 de enero de 2015 suscrito por XXXXX –Notaría Séptima E de Bucaramanga, mediante el cual informa que el trámite de sucesión del causante XXXXX con C.C. XXXXX, se llevó a cabo en esa Notaría de mutuo acuerdo y culminó por escritura pública número 7788 del 30 de diciembre de 2014, actuando como apoderado de los interesados el abogado XXXXX identificado con C.C. XXXXX.

6.2.1.6. Diligencia de visita administrativa realizada el 15 de abril de 2016 (folios 342 y ss), por medio del cual se estableció que los documentos que sirvieron de soporte para la expedición de la certificación fueron la copia del formulario de declaración de renta y complementarios No. 2104304842029 y copia del formato del sistema Muisca impreso el día 12/12/2012 a las 10:26 que se titula obligaciones por contribuyente.

En desarrollo de la diligencia se allegó copia de los lineamientos establecidos por la DIAN donde se reglamenta el proceso para expedir certificaciones dentro del proceso de sucesión, el cual se titula "RECUPERACION DE CARTERA A TRAVES DE UN PROCESO DE SUCESION".

Finalmente, se adelantó una revisión a tres expedientes tramitados en el mes de diciembre de 2014, siendo posible verificar que, a efectos de establecer si existen procesos pendientes contra las personas que se encuentran en listado, se envía un oficio semanal a las Seccionales en el que se relacionan las solicitudes que han sido radicadas; este oficio, se anexa a los expedientes de la certificación. Esta información reposa en un buzón donde se encuentran los documentos remitidos a las Seccionales del país.

Por último, se allegan a la actuación copia de los oficios 1-04-242-8022-029 de fecha 18 de noviembre de 2014 y el oficio 1-04-242-8022-031 de fecha 9 de diciembre de 2014, suscritos por XXXXX.

6.2.1.7. Correo electrónico de fecha 8 de julio de 2016 (folios 416 a 417), remitido por el jefe del GIT de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la Seccional de Bucaramanga, por medio del cual informa que una vez revisados los archivos de esa dependencia no se encontraron copias de oficios donde se haya solicitado verificar la existencia de procesos de determinación o de discusión a nombre del causante XXXXX NIT XXXXX, como tampoco respuestas acerca de dicha verificación.

Respecto a la revisión de la existencia de procesos de cobro o facilidades de pago a nombre del señor XXXXX, se informa que el día 12 de diciembre de 2014, fue consultó el SIE de obligación financiera, según reporte adjunto, en el que no se reflejan obligaciones pendientes de pago y que, por el contrario, aparece un saldo a favor por el concepto de renta año gravable 2013.

6.2.1.8. A folio 498 fue incorporado un correo electrónico fechado el 18 de septiembre de 2017, mediante el cual XXXXX, Jefe de la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga informó que verificados los aplicativos del área, no existe a la fecha de la comunicación proceso de cobro contra XXXXX por obligaciones fiscales pendientes de pago, ni tampoco en expedientes ya terminados y que la última declaración de renta fue presentada por el año 2014, con saldo a favor.

6.2.2. Testimoniales

6.2.2.1. XXXXX (folio 60 a 64), manifestó respecto de los hechos objeto de investigación, que el día 3 o 4 del mes de diciembre de 2014, sin lograr precisar fecha exacta, se acercó a las instalaciones de la DIAN en Bucaramanga, con el fin de solicitar un paz y salvo necesario para el trámite de la sucesión de su padre XXXXX, que se estaba adelantando en la Notaria 7°. Por tal razón, habló con un funcionario de la Seccional de Bucaramanga con el fin de conocer saber si el paz y salvo podía salir antes de que terminara el año 2014.

Indicó que el servidor público que lo atendió fue muy cordial, pero le advirtió que antes de su solicitud había unas ochenta más, razón por la cual iba a ser difícil que la certificación saliera en el 2014. El testigo indicó que no obstante lo anterior, el mismo funcionario le indicó que:

“tranquilo que no me preocupara porque estábamos para ayudarnos, palabras más palabras menos lo que me dijo fue que el me colaborara pero que le ayudara con una suma de dinero con cuatrocientos mil pesos que eso no tenía problema que cuanto antes sacaba la certificación, como debía hacer la declaración parcial del 2014 hasta diciembre que cuanto la trajera, trajera ese dinero y eso fue todo”.

Ante este planteamiento y dado que en la diligencia se encontraba presente el investigado XXXXX, el testigo manifestó expresamente que dicha persona era aquella con la que había mantenido la conversación arriba reseñada, cuando de manera textual indicó que: *“Es el señor aquí presente, está vestido de camiseta de rayas verdes, azules, blancas, jean azul y zapatos negros”.* En tal sentido el Despacho dejó constancia de que: *“el testigo señala al funcionario XXXXX quien se encuentra presente en la diligencia”.*

Agregó que la conversación sostenida con el señor XXXXX se sostuvo en el escritorio de éste, es decir en el tercer piso donde queda ubicada el área de cobranza, que no recordaba bien quien era la persona que le había señalado al funcionario XXXXX como el encargado de tramitar el paz y salvo; sin embargo, afirmó que creía que había sido en la portería donde lo habían direccionado ante el funcionario XXXXX, porque llevaba el oficio de la Notaria.

Señaló que no pagó la suma exigida por el funcionario XXXXX y frente a la pregunta de si había sido la persona que llamó a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, manifestó:

“Tengo una amiga que es amiga personal del director y era difícil comunicarme o ir directamente hablar con el director le dije me paso esto me parece que el director debe saberlo y quería decírselo personalmente sin embargo no pude obtener el teléfono ni el acceso al Director estaba de viaje no recuerdo exactamente ella le comentó que se trataba de algo así que era para esa gestión, horas después me llamo el asesor jurídico no recuerda el nombre me llamo la doctora Hortensia no recuerdo el apellido, me dijo que le habían preguntado al señor XXXXX que él había aceptado los hechos que lamentaba los hechos y me pidió excusas en representación de la entidad.”

Manifestó que el paz y salvo que requería era el que certificaba que no se tenían deudas pendientes con la DIAN, el cual era necesario para tramitar la sucesión de su papa, advirtiendo que ese mismo día el señor Félix ingresó al sistema y logró verificar que su padre no tenía deudas pendientes con esa Entidad, por lo que días después de presentada la queja le fue entregado el paz y salvo.

A las preguntas elevadas por el apoderado del disciplinado, señaló que si conocía como se adelantaba el trámite de sucesión y que éste había iniciado el primer día hábil de diciembre aclarando que no recordaba si había sido el primero o el dos, preciso que presumía que su amiga de nombre XXXXX era la persona que le había comentado la situación que se había presentado al Director Seccional, pues era amiga personal de este, señaló que el día que se trasladó al despacho del señor XXXXX a realizar el trámite del paz y salvo, no se encontraba acompañado de ninguna persona.

Adujo que la notaría expide un oficio con destino a la DIAN y el interesado lleva el oficio, actuación que fue realizada por él, refirió que no recordaba exactamente si el señor XXXXX le manifestó el término para obtener el paz y salvo, pero si estaba seguro que le había dicho que no alcanzaba a salir en el 2014, indicó que se dirigió solo a realizar el respectivo tramite, precisando que fue entre el 4 o 5 de diciembre, pero que para mayor claridad se contaba con el oficio de recibido.

Posteriormente, durante el desarrollo de la instrucción, el testigo XXXXX, fue escuchado por segunda ocasión, diligencia en la que ratificó su versión inicial y en la cual agregó que los hechos denunciados se presentaron el mismo día en que recibió el oficio por parte de la Notaría 7, que no accedió a la solicitud de dinero realizada por el funcionario XXXXX, quien además le había reiterado que estaban para ayudarse y que además le efectuó otros comentarios, como el de que en un caso similar abogado le había manifestado que era justo reconocerle al funcionario por su colaboración y que tenía un hijo que estaba estudiando biomédica, por lo que era difícil su situación.

6.2.2.2. XXXXX (Jefa de la División de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga), dio cuenta en su testimonio (folios 67 a 70), sobre las circunstancias en que se desarrolló la reunión donde se puso en conocimiento los hechos investigados. Aparte, refirió que el señor Félix era el encargado de recibir los oficios que llegaban de las notarías y juzgados, así como de la expedición de los certificados de paz y salvo requeridos en los procesos de sucesión. Frente a la afirmación consignada en el informe de fecha 15 de diciembre de 2014 advirtió que no recordaba mayores detalles, sólo que el funcionario estaba muy nervioso y se le notaba poca coherencia.

Finalmente, precisó que el trámite para la expedición del paz y salvo requerido por parte de las Notarías, se fundamenta en el artículo 844 del Estatuto Tributario, que establece que en aquellas sucesiones cuya cuantía sea superior a 700 UVT debe informarse a la división de cobranzas de la seccional competente o sea contribuyente para que se le expida la certificación indicando si tiene o no deudas, contando con un término de 20 días para su respectiva expedición.

6.2.2.3. XXXXX (Jefa del Grupo Interno de trabajo Gestión de Cobranzas de la Dirección seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga y Jefe inmediata del disciplinado), señaló que las funciones que cumplía el servidor público investigado era el apoyo al grupo de trabajo expidiendo las certificaciones de las sucesiones, atención al público y las demás propias de su cargo (folios 71 a 74).

Finalmente indicó que cuando se apertura un proceso de sucesión las notarías dependiendo de la cuantía, le solicitan a la DIAN que para continuar con el trámite respectivo se expida una certificación de las obligaciones fiscales a cargo del causante, ante esa solicitud la DIAN dispone de 20 días para contestar dentro de ese término se envían solicitudes a las demás áreas para dar una respuesta acertada, advirtió que el oficio realizado por la Notaría llega directamente por a través de esta o directamente por los herederos.

6.2.2.4. XXXXX (funcionaria del Despacho de la Dirección seccional de Impuestos y aduanas de Bucaramanga), además de relatar detalles de tiempo, modo y lugar de la reunión en la que se pusieron en conocimiento los hechos investigados, aseveró que el investigado es una persona confiable, distinguido por su buen carácter y compañerismo.

6.2.2.5. XXXXX (Director Seccional de Impuestos y aduanas de Bucaramanga), manifestó frente a los hechos que fueron objeto de esta investigación, que el informe inicialmente remitido, es acorde con la verdad de los hechos consignados, los cuales también fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía.

En fecha 28 de abril de 2015 (folios 229 a 232), fue escuchado por segunda vez, oportunidad en la cual agregó que la reunión en la que se puso en conocimiento los hechos investigados se había realizado el viernes 12 de diciembre de 2014, que no conocía a la señora XXXXX y reiteró que el contenido del informe de servidor público suscrito por él, correspondía a la verdad de los hechos, con ocasión de los cuales ordenó el traslado del funcionario y solicitó a la jefa del área de

cobranzas que se encargara directamente del trámite de expedición del paz y salvo con destino al trámite de la sucesión del causante XXXXX.

6.2.2.6. XXXXX (Abogado de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga) en las diligencias de testimonio y ampliación rendidas ante este Despacho (folios 222 a 225), además de haber relatado las circunstancias en que se desarrolló la reunión en la que se expusieron los hechos investigados, manifestó que el día en que ésta tuvo lugar (12 de diciembre de 2014), se comunicó vía telefónica con XXXXX, quien le manifestó su molestia con la DIAN, al reclamar que los funcionarios de la entidad no tenían que cobrarle a los usuarios por cumplir sus deberes, tal y como lo había hecho el investigado, ante lo cual el testigo le pidió excusas por dicho comportamiento y le informó que el certificado sería expedido de forma rápida, por lo que los datos del señor XXXXX, fueron suministrados por el Director.

6.3. VALORACIÓN PROBATORIA

6.3.1. Cuestiones preliminares

El Despacho considera procedente, previo al análisis de fondo, enfatizar que, en el marco probatorio del caso en concreto, ha sido excluida como medio de prueba la supuesta confesión que presuntamente y respecto de los hechos materia de investigación, efectuara el disciplinado XXXXX en la reunión concertada por el Director Seccional y que sirvió de fundamento al informe mediante el cual se dio origen a esta actuación disciplinaria. Dicha exclusión, se sustentó en los argumentos que al respecto formulara este operador disciplinario en el auto por el cual se evaluó la investigación mediante formulación de cargos, por lo que no resulta necesario retomarla, máxime cuando allí quedó claramente establecido que dicho medio probatorio no se encontraba estructurado por la inobservancia de los elementos legales en los que se debe soportar su validez.

Esta reiteración, a juicio de este operador, resulta pertinente, en la medida en que, estando ad portas de la definición de la situación jurídica del investigado mediante la formulación del correspondiente fallo, es posible advertir que el planteamiento probatorio se delimita esencialmente a las aseveraciones que bajo la gravedad del juramento efectuara XXXXX en el testimonio rendido durante la instrucción de este proceso y que se constituye como la pieza probatoria fundamental, al ser aquella la única que de forma directa abordó el hecho base de la imputación.

Así las cosas, resulta evidente que el problema jurídico que, conforma el eje central de este análisis, estriba en determinar si el testimonio en mención puede operar como sustento probatorio del fallo, habida cuenta las condiciones particulares en que acaeció el hecho objeto de investigación y la descripción que del cargo se efectuara en la resolución por la cual se adelantó este juicio disciplinario. En consecuencia, es menester hacer acopio de los planteamientos que en torno a este tema a efectuado la judicatura, para así tener un panorama crítico acertado respecto del alcance que un testimonio puede tener al momento de valorar una situación particular.

6.3.2. Del valor probatorio del testigo único

Sea procedente indicar que nuestro sistema jurídico, en lo concerniente al aspecto probatorio, ha sobrepasado la noción de tarifa legal que lo permeaba en pretéritas épocas, asumiendo el legislador un sistema menos formalista y que fue reemplazado por otro basado en el pleno reconocimiento de las reglas de la lógica, la experiencia y la ciencia.

Este sistema de valoración que impera en el derecho penal, como en el disciplinario y que se denomina en lo que se conoce como “sana crítica”, se encuentra inserto en un contexto en el que no se privilegia una tarifa o valor predeterminado de una prueba, ni el aporte cuantitativo de varias, sino al análisis razonable y coherente de una situación a través de las reglas arriba referidas, por lo que resulta procedente conceder valor al testigo único como una fuente viable y legítima de convicción, atendiendo el contexto ponderado de sus planteamientos y las características o particularidades inherentes a la forma en que dicho testigo tuvo contacto con la situación o hecho objeto de la investigación.

En el contexto del proceso penal, es donde se ha avanzado de forma notoria en la reivindicación del testigo único como fuente y soporte de una decisión. No por otra razón la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha manifestado que:

“...a pesar del histórico origen vivencial o práctico de la regla testis unus, testis nullus, hoy no se tiene como máxima de la experiencia, por lo menos en sistemas de valoración racional de la prueba como el que rige en Colombia (C. P. P., arts. 254 y 294), precisamente porque su rigidez vincula el método de evaluación probatoria a la anticipación de una frustración de resultados en la investigación del delito, sin permitir ningún esfuerzo racional del juzgador, que además es contraria a la realidad (más en sentido material que convencional) de que uno o varios testimonios pueden ser suficientes para conducir a la certeza. Todo ello desestimularía la acción penal y se opone a la realidad de que en muchos casos el declarante puede ser real o virtualmente testigo único e inclusive serlo la propia víctima.

No se trata de que inexorablemente deba existir pluralidad de testimonios o de pruebas para poderlas confrontar unas con otras, única manera aparente de llegar a una conclusión fiable por la concordancia de aseveraciones o de hechos suministrados por testigos independientes, salvo el acuerdo dañado para declarar en el mismo sentido. No, en el caso del testimonio único lo más importante, desde el punto de vista legal y razonable, es que existan y se pongan a funcionar los referentes empíricos y lógicos dispuestos en el artículo 294 del Código de Procedimiento Penal, que no necesariamente emergen de otras pruebas, tales como la naturaleza del objeto percibido, la sanidad de los sentidos por medio de los cuales se captaron los hechos, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió, la personalidad del declarante, la forma como hubiere declarado y otras singularidades detectadas en el testimonio, datos que ordinariamente se suministran por el mismo deponente y, por ende, dan lugar a una suerte de control interno y no necesariamente externo de la prueba.

Con una operación rigurosa de control interno de la única prueba (aunque sería deseable la posibilidad de control externo que pueda propiciar la pluralidad probatoria), como la que ordena singularmente la ley respecto de cada testimonio o medio de prueba (art. 254, inciso 2° C. P. P.), también es factible llegar a una conclusión de verosimilitud, racionalidad y consistencia de la respectiva prueba o todo lo contrario. Ciertamente, la valoración individual es un paso previo a la evaluación conjunta, supuesto eso sí el caso de pluralidad de pruebas, pero ello que sería una obligación frente a la realidad de la existencia de multiplicidad de medios de convicción, no por lo mismo condiciona el camino a la adquisición de la certeza posible aún con la prueba única”²

Sobre este punto dicho tribunal había manifestado que:

“El testimonio único purgado de sus posibles vicios, defectos o deficiencias, puede y debe ser mejor que varios ajenos a esta purificación. El legislador, y también la doctrina, ha abandonado aquello de testis unus, testis nullus. La declaración del ofendido tampoco tiene un definitivo y

²CSJ, Sala de Casación Penal MP. JORGE ANIBAL GOMEZ GALLEG0. PROCESO 13119, DICIEMBRE 15 de 2000

apriorístico demérito. Si así fuera, la sana crítica del testimonio, que por la variada ciencia que incorpora a la misma y mediante la cual es dable deducir cuánto se miente y cando se dice la verdad, tendría validez pero siempre y cuando no se tratase de persona interesada o en solitario. Estos son circunstanciales obstáculos, pero superables; son motivos de recelo que obligan a profundizar más en la investigación o en el estudio de declaraciones tales, pero nunca pueden llevar al principio de tenerse en menor estima y de no alcanzar nunca el beneficio de ser apoyo de un fallo de condena”³.

6.3.3. Del caso en concreto

A partir del testimonio de XXXXX, se tuvo conocimiento inicial de las circunstancias de modo, tiempo y lugar bajo los cuales se consolidó el hecho irregular. Conforme al relato que bajo la gravedad del juramento rindiera dicha persona en su testimonio inicial, como en la ratificación posterior, se estableció que, en diciembre de 2014, se acercó a las instalaciones de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga con el fin de solicitar un paz y salvo, documento que requería para el trámite de la sucesión de su padre XXXXX; trámite que adelantaba ante la Notaría Séptima del Círculo de dicha ciudad. Estando allí, alude a que fue direccionado al área de cobranzas o de cobro coactivo, la cual queda en el tercer piso de la sede, lugar donde fue atendido por el servidor público encargado de diligenciar dicho documento.

Agregó que a continuación, al entablar conversación con el funcionario, le preguntó sobre la posibilidad de que el certificado fuera expedido ese mismo año, es decir en el año 2014, ante lo cual el servidor le respondió que previas a su solicitud había aproximadamente ochenta requerimientos más en trámite; no obstante, y en este punto es donde se genera el hecho cuestionable, el mismo servidor le insinuó que estaban para ayudarse y que le podía prestar su colaboración en el sentido de que, a cambio de \$400.000, le podía expedir la certificación una vez le aportara la declaración de renta parcial de 2014, es decir con la rapidez que requería.

Ahora bien, en el desarrollo de la diligencia, más precisamente en la practicada el 28 de enero de 2015, el testigo corroboró que el servidor público que lo atendió y que le formuló la propuesta, se encontraba de cuerpo presente, señalando a XXXXX, quien acudió a la diligencia en compañía de su defensor.

La descripción de las circunstancias del hecho así efectuadas por XXXXX en su testimonio, como la corroboración del funcionario que le formuló la irregular proposición es por sí sola y a juicio de este operador coherente, amén que es posible apreciar que la prueba fue practicada no solo en cumplimiento de los parámetros legales en cuanto a la verificación de sus formalidades, es decir que fue realizada bajo la gravedad del juramento y la acotación del marco constitucional y legal que dicha diligencia exige, sino también en cuanto a la verificación de las garantías procesales por la observancia de las atribuciones en cabeza del investigado, habida cuenta que se le comunicó oportunamente y lo más importante, asistió en compañía de su defensor, pudiendo intervenir de una forma activa mediante el despliegue de un interrogatorio al testigo. Por ende, la prueba testimonial en comento, le permitió al disciplinado ejercer de manera puntual y efectiva su derecho de defensa, en la medida que pudo ejercitar su derecho de contradicción, lo cual legitimó la práctica de dicho medio probatorio.

En cuanto a los aspectos de fondo, considera este operador que el testimonio de XXXXX, constituyó un relato desapasionado y diáfano que le otorga la credibilidad necesaria como para dar pleno fundamento al cargo imputado; sin embargo, con base en el análisis integral del acervo probatorio,

³ CSJ, Sala de Casación Penal. MP. GUSTAVO GÓMEZ VELÁSQUEZ. CASACION JULIO 12 de 1989

tal y como lo exige el artículo 141 del C.D.U, esta prueba se ve complementada con otros medios que redundan en la consolidación de su solidez. En efecto, advierte el Despacho, que el relato encuentra corroboración a través de otros medios probatorios, que al ser interrelacionados de manera integral le da mayor soporte a la prueba testimonial y directa cuya fuente fue el propio quejoso.

Es así como se advierte que el primer aspecto que es objeto de comprobación, tiene que ver o hace referencia a la presencia misma del testigo en el lugar de los hechos para el mes de diciembre de 2014, es decir, en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, habida cuenta que se ha demostrado que el día 9 de diciembre de 2014 radicó el oficio por medio del cual la Notaría Séptima del Círculo de Bucaramanga, informó a la administración de impuestos sobre la autorización de la sucesión de XXXXX; oficio de fecha 4 de diciembre de 2014 y cuyo número de registro en el GIT de Documentación de la DIAN corresponde al 023611 siendo la hora de recibido las 3:05 de la tarde. Esta información permite corroborar plenamente el primer aspecto mencionado por XXXXX, toda vez que establece su asistencia a la sede de la DIAN en Bucaramanga, para iniciar el trámite ante dicha entidad, el cual era requerido para avanzar en la sucesión del causante. Con este planteamiento probatorio se establece las circunstancias de tiempo y lugar en el que se contextualizó el hecho objeto de investigación.

Un segundo aspecto que se ha evidenciado, se relaciona con el hecho de que XXXXX, para la época en que tuvo acaecimiento la conducta a él imputada, tenía la condición de servidor público, toda vez que ingresó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales el 2 de junio de 1993 y que para el mes de diciembre de 2014 laboraba en el Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Cobranzas de la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, ocupando el cargo de Analista I Código 201 Grado 01. Ahora bien, dentro de las funciones relacionadas con el aludido cargo, se encontraba la de brindar apoyo en la liquidación del valor de las obligaciones que figurasen en obligación financiera y cuenta corriente a cargo de los contribuyentes solicitantes para atender en oportunidad y veracidad las certificaciones de ley.

A lo precedente se suma el hecho de que XXXXX, en su condición de Jefe GIT Gestión Cobranzas de la DIAN – Bucaramanga, indicó que en el período comprendido entre el 15 de febrero de 2011 hasta el 14 diciembre de 2014 y entre el 1 de diciembre y hasta el 15 de diciembre del año 2014, el disciplinado XXXXX gestionó 176 certificaciones de sucesiones y recibió 168 solicitudes entre sucesiones y liquidaciones voluntarias de sociedades, junto con las solicitudes realizadas por nivel nacional que no son cuantificables, teniendo como carga laboral un total de 344 solicitudes de certificaciones. A lo que adhiere que, bajo la gravedad del juramento, las servidoras públicas XXXXX y XXXXX, reiteraron que para el mes de diciembre del año 2014 el encargado de expedir los paz y salvos requeridos por las Notarías y los Juzgados en los trámites de sucesión que estos adelantaban, era XXXXX.

A partir de la plena demostración de tales aspectos, es posible confirmar y corroborar el testimonio de XXXXX en lo concerniente a la identidad del servidor público que atendió su solicitud, habida cuenta que no podía ser una persona diferente a XXXXX, al ser éste el encargado del trámite de las certificaciones de sucesiones, las cuales eran recibidas y gestionadas específicamente por dicho funcionario. Este elemento, además de situar al disciplinado en forma irrefutable en el contexto fáctico del hecho generador de la imputación disciplinaria, permite apreciar la solidez del testimonio de XXXXX, otorgándole a este Despacho las condiciones que permiten apreciar en un juicio racional y razonable, la credibilidad en sus aseveraciones.

Ahora bien, examinado el contexto en el que se generó el hecho y particularmente las características de tiempo y lugar, las cuales se encuentran debidamente corroboradas, resulta menester examinar ahora el hecho en sí y de manera particular el modo en que la conducta

irregular se materializó. A este efecto, se deduce que el quejoso, una vez establecida el área en la que debía adelantar el trámite para la expedición de la certificación previa entrega del oficio emitido por la Notaría 7 de Bucaramanga, se presentó en el área de trabajo del servidor público encargado de dicha gestión, que, como pudo comprobarse era, para la época de los hechos, el investigado XXXXX.

Sobre este episodio en particular, el testigo aseveró que el funcionario lo atendió de manera amable y que le preguntó sobre la posibilidad de que la certificación o paz y salvo pudiese salir en esa anualidad, no obstante que transcurría en ese momento el mes de diciembre de 2014. Resalta el testigo que el investigado le comentó que, previamente a su solicitud, había otras ochenta solicitudes, lo cual era un indicativo de que el documento requerido no saldría antes de finalizar el año 2014. En lo concerniente a este punto cabe resaltar que la aseveración del testigo en torno a la carga laboral y acumulación de solicitudes que debía gestionar el disciplinado, se corrobora gracias a la información que al respecto efectuara XXXXX, en su condición de Jefe GIT Gestión Cobranzas de la DIAN – Bucaramanga, cuando, como se observó en párrafos precedentes, indicó el volumen de trámites que al respecto debía gestionar el disciplinado entre certificaciones para sucesiones y liquidaciones voluntarias de sociedades. Por lo tanto, el relato cobra mayor credibilidad, por cuanto este punto sólo pudo haberlo conocido el testigo de boca del disciplinado, quien era consciente del volumen de solicitudes a su cargo y que antecedían a la que le era presentada en ese momento.

Ahora bien, es a partir de este punto donde se evidenció el surgimiento de la oportunidad y particularmente de la excusa que el investigado sustentó para formular la solicitud irregular, cuando le planteó al usuario y quejoso que estaban para colaborarse o ayudarse, comunicándole que a cambio de \$400.000, podía obtener la certificación e incluso el mismo día en que aportara la declaración de renta parcial correspondiente al año 2014. Esta fue la “colaboración” que el investigado ofreció al quejoso para que éste pudiese obtener de forma más expedita la certificación requerida a fin de agilizar el trámite de la sucesión de su padre que venía adelantando ante la Notaría Séptima de Bucaramanga y que a juicio de este operador resulta coherente ante la expectativa del usuario de que la gestión se evacuara rápidamente, aspecto que le permitió al disciplinado el dilucidar la posibilidad de obtener un provecho irregular gracias a dicha necesidad, planteándole una solución a cambio de una solicitud en dinero.

Por consiguiente, para el despacho resulta diáfana la existencia de la solicitud irregular que es objeto de reproche, por cuanto su corroboración surge no sólo de la verificación de las circunstancias concomitantes que acaecieron el 9 de diciembre cuando el quejoso se acercó a adelantar el trámite ante la entidad, tal y como fuera planteado en párrafos precedentes, sino también por el hecho de que la forma clara, expresa y concordante con el que fue efectuado el relato en torno a estos aspectos puntuales, permite inferir la credibilidad necesaria que se le debe exigir al relato. A ello se suma el hecho de que no existe, ni fue planteado la presencia de algún antecedente que permitiese inferir la presencia de animadversiones o algún tipo de situación demostrativa de que el planteamiento de XXXXX hubiese sido fruto de una retaliación contra XXXXX, máxime cuando del relato e inclusive de la información suministrada por el propio investigado se deduce que no existía entre él y el usuario algún tipo de relación previa al episodio investigado.

En conclusión, para el Despacho existen las condiciones probatorias que demuestran plenamente la irregularidad estructurada en la solicitud dineraria que efectuara el servidor público vinculado a esta actuación a cambio del ofrecimiento de un beneficio derivado en la agilización de un asunto propio de su función y cargo, por lo que la conducta se materializó aun cuando no se hubiese obtenido el beneficio requerido, no siendo realmente trascendente para ello, las circunstancias en las cuales se diera a conocer el hecho por parte del afectado, quien obró de manera coherente al poner en conocimiento de la administración la irregularidad planteada.

Tampoco se avizora que el suministro de la información que sobre la existencia de la irregularidad hiciera el directo afectado, hubiese versado como una estrategia soterrada por parte de XXXXX para la obtención de un objetivo predeterminado, es decir como medio para presionar u obtener de forma expedita la certificación o paz y salvo por él requerido, y a costa de la situación del investigado; ello en consideración a que la administración tiene un término de veinte días para expedir la certificación y que en el caso particular, el documento requerido se obtuvo en un lapso de tres o cuatro días desde la presentación del oficio expedido por la Notaría.

Para este operador, no se verifica ninguna evidencia que señale, siquiera tangencialmente, que hubiese existido de parte de XXXXX, una estrategia subrepticia para la obtención del documento, mediante la formulación o puesta en conocimiento del hecho irregular, habida cuenta que con las verificaciones realizadas por este Despacho se obtuvo la impresión de la consulta realizada al sistema MUISCA el día 12 de diciembre de 2014, en la cual se verificó que el causante y contribuyente XXXXX, para los períodos correspondientes a los años 2006 al 2014, se encontraba "AL DIA" con sus obligaciones tributarias y que incluso para el año 2013 se reporta un saldo a favor por valor de \$ 11.620.000. Esta información obtenida de los registros oficiales de la entidad, es decir de la DIAN, determinó la respuesta dada por la Jefa de la División de Recaudo y Cobranzas, para en su momento expedir la certificación requerida.

6.4. DE LA TIPICIDAD DISCIPLINARIA

El artículo 48 de la Ley 734 de 2002 establece un catálogo taxativo de conductas que ostentan la calidad de gravísimas. Así, el numeral 1 del citado artículo prescribe que son faltas gravísimas las siguientes: 1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la Ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo.

La norma transcrita es un tipo en blanco cuyo complemento se encuentra en el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000). De este modo, es preciso realizar un ejercicio de adecuación típica penal, con el objeto de que, por remisión, dicha infracción a la luz de lo dispuesto por el artículo 48 numeral primero del Código Disciplinario Único, corresponda a un tipo disciplinario.

En el caso particular, objeto de estudio, se advierte que la conducta del funcionario XXXXX, se adecuó desde la perspectiva objetiva a la descripción típica del estatuto penal consagrada en el artículo 404, que establece:

"ARTICULO 239. CONCUSIÓN. El servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión [...]"

Este tipo penal exige un **sujeto activo cualificado** jurídicamente y singular, esto es, la conducta debe ser cometida por un servidor público que abusa de su cargo o función. Sobre este punto, existen pruebas suficientes para determinar que el señor XXXXX es un servidor público adscrito a Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, a saber: el oficio No. 100206214 de fecha 22 de enero de 2015 y la respuesta remitida por la Coordinación de Historias Laborales de la Subdirección de Gestión de Personal de la Dian que así lo certifican.

Así mismo se ha demostrado aparte de la condición funcional del sujeto activo, el que existió un **abuso de su cargo o función**. En efecto, el servidor público abusa del cargo o de la función cuando apartando su conducta de las normas constitucionales y legales que lo regentan constriñe, induce o solicita a alguien a dar o prometer dinero, al respecto se tiene que las funciones correspondientes

al cargo de Analista I Código 201 Grado 01 de la dependencia donde laboraba el disciplinado para el mes de diciembre de 2014, se relacionaban entre otras con el apoyo en la liquidación del valor de las obligaciones que figuren en obligación financiera y cuenta corriente a cargo de los contribuyentes solicitantes para atender en oportunidad y veracidad las certificaciones de ley, así se estableció que entre el 15 de febrero de 2011 y el 14 de diciembre de 2014, gestionó 176 certificaciones de sucesiones y recibió 168 solicitudes entre sucesiones y liquidaciones voluntarias de sociedades, teniendo como carga laboral un total de 344 solicitudes de certificaciones y que en dicho ejercicio funcional y de forma específica para diciembre 9 de 2014, el investigado, contrariando el marco constitucional y legal, incurrió en una conducta reprochable.

Dicha conducta se materializó, en la concreción del verbo rector “solicitar”, tal y como se verificó en el análisis adelantado en el acápite precedente, al ser constatado que el día 9 de diciembre de 2014, cuando XXXXX se presentó en la Seccional de Bucaramanga, se dirigió al tercer piso y radicó ante el funcionario investigado el oficio remitido por la Notaría 7ª del circulo de Bucaramanga, a través del cual se requería se certificara si a la fecha el causante XXXXX tenía obligaciones pendientes con la DIAN. Allí el quejoso preguntó al disciplinado si la certificación alcanzaba a salir antes de terminar el mes de diciembre, oportunidad que éste aprovechó para solicitar indebidamente la suma de cuatrocientos mil pesos, abusando de su posición y función en el área de Cobranzas, con lo cual ofrecía la expectativa de expedir la certificación en un tiempo más expedito.

Por último, el tipo penal exige un ingrediente normativo, como lo es el que la solicitud debe ser dinero o cualquier otra utilidad indebida. Sobre este punto, con el testimonio de XXXXX, permite concluir que dicha solicitud ascendió a la suma de cuatrocientos mil pesos que, no obstante, no haber sido entregados, no impidió la consolidación de la concusión, habida cuenta que dicho tipo penal es de mera conducta más no de resultado

En este orden de ideas, una vez comprobados los requerimientos de carácter objetivo que describe el legislador en el artículo 239 del C. Penal, y teniendo en cuenta que el delito de concusión allí descrito es una conducta punible en la que se incurre a título de dolo, es posible concluir que se encuentra comprobada la falta disciplinaria por la cual se le formulara cargos al disciplinado, amén que realizó objetivamente una descripción consagrada en la ley penal como un delito sancionable bajo dicha forma de culpabilidad, tal y como lo exige el numeral 1º del artículo 48 de la ley disciplinaria y que dicha conducta se efectuó, como se ha señalado, con un evidente abuso del cargo y de la función.

6.5. DE LA ILICITUD SUSTANCIAL

Los servidores públicos deben tener siempre presente el deber de sujetar su función y asegurar la prevalencia del interés general, de donde surge su responsabilidad con ocasión de la vulneración de los principios de legalidad, transparencia, honradez y lealtad.

De esa forma, la conducta típica enunciada resulta sustancialmente contraria al ordenamiento jurídico vigente, puesto que el servidor implicado debió actuar como lo demandan las normas de carácter legal y reglamentario, pese a lo cual dejó de hacerlo, transgrediendo los deberes que implican el ejercicio de la función pública.

Así las cosas, el disciplinado al abusar de su cargo mediante la indebida solicitud de dinero para realizar una actuación propia de su cargo, afectó la legalidad, transparencia, moralidad, lealtad y pulcritud exigible de su condición de servidor público, y que dicho comportamiento no encuentra justificación, configurándose de ese modo el elemento de ilicitud sustancial o antijuridicidad que demanda la estructuración de la falta disciplinaria.

Se reitera en este sentido el planteamiento expuesto en su debido momento, cuando al formular el cargo se enfatizó que los servidores públicos, al asumir sus cargos, se comprometen a cumplir con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias (Arts. 6 y 122 Constitución Política y 27 Código Disciplinario Único), lo que significa que la realización de comportamientos expresamente prohibidos o calificados como atentatorios del ordenamiento, sin ninguna justificación, pueden resultar violatorios de sus deberes funcionales expresamente definidos.

Al respecto, debe señalarse que la conducta resulta antijurídica desde todo punto de vista, porque con ella el disciplinado atentó contra los principios de la administración tales como la legalidad, la buena fe y la transparencia, al actuar contrariamente al deber de fidelidad, lealtad y diligencia esperado para con la administración pública.

Conforme a lo anterior, es válido declarar abastecido el presupuesto de antijuridicidad de la conducta al tenor de lo señalado en el artículo 5º de la Ley 734 de 2002, ya que hubo falta al deber funcional sin justificación alguna conocida.

6.6. DE LA CULPABILIDAD

En lo que respecta a la forma de culpabilidad, el artículo 13 de la Ley 734 de 2002 determina que las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa.

El dolo ha sido entendido como la dirección consciente de la voluntad para obtener un resultado típico y antijurídico, previsto y querido. Dicho en otras palabras, en el dolo se presentan elementos intelectivos o cognitivos (conocimiento, representación mental y previsión de la conducta), volitivos (actitud consciente de situarse al margen del derecho) y ejecutivos (materialización sin justificación).

En este caso la falta endilgada al servidor público XXXXX, se ejecutó a título de DOLO, por cuanto del análisis de las pruebas obrantes se pudo establecer lo siguiente:

En efecto, es procedente advertir que el disciplinado, en lo concerniente al aspecto intelectual o cognitivo, tenía pleno conocimiento sobre la connotación irregular de su conducta, pues tal y como se estableció en la actuación disciplinaria, no obstante, su experiencia en el servicio público y en la ejecución de las funciones asignadas, así como su compromiso con la aplicación de los principios que rigen la administración pública desde el momento en que asumió el cargo, aprovechó, de una parte, su posición de conocimiento sobre el caso en particular del usuario y de la otra, el conocimiento sobre las atribuciones funcionales que le fueron conferidas en razón a ser el servidor público que dentro de la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas, se encargaba de gestionar los requerimientos para los trámites de sucesiones y de sociedades en liquidación. Además, era consciente de que realmente tenía a su disposición la pronta expedición del certificado requerido por el usuario, ya que no de otra forma se explica el que, al notar dicha necesidad, le hubiese mencionado a aquel que el paz y salvo lo podía obtener apenas llevara la declaración de renta parcial del año 2014, junto con el dinero solicitado.

En cuanto al aspecto volitivo se evidenció que no obstante la connotación de la irregularidad y el conocimiento de la ilicitud derivado de su capacidad y conocimiento de la misma, así como de su trayectoria en las funciones encomendadas, quiso el disciplinado su realización de manera tal que le planteó al usuario que podía contar con él y que se podía establecer una relación de mutuo beneficio, abonando así y de manera previa el terreno para plantear la solicitud dineraria; actuar éste con el cual finalmente materializó su conducta, al encarar al usuario e indicarle que el

beneficio de obtener prontamente el documento, tenía un costo, lo cual se ejecutó con la solicitud de cuatrocientos mil pesos.

Así las cosas, es pertinente señalar, que los elementos constitutivos del dolo se constatan en el actuar del funcionario, sin que se advierta causal de justificación de responsabilidad alguna o vicio en la voluntad o consentimiento del mismo, teniendo en cuenta que, como se reitera, que el disciplinado se vinculó con la administración de impuestos y aduanas nacionales desde el año 1992, lo que le permitía conocer de manera amplia, el compromiso, los valores y principios atados a la dignidad de su cargo.

Así, se tiene que el servidor público XXXXX conocía la irregularidad que desarrollaba y aun así se determinó consciente y libremente a su desarrollo, aceptando con anterioridad las consecuencias derivadas de la misma.

7. CALIFICACIÓN DE LA FALTA

Conforme al artículo 42 de la Ley 734 de 2002, las faltas disciplinarias son gravísimas, graves y leves; las primeras se encuentran taxativamente descritas en el artículo 48 de la misma norma, mientras que las demás se estructuran por razón del incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones, o la violación al régimen de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados en la Constitución y la ley, en los términos del artículo 50 ídem, siguiendo los lineamientos contemplados en el artículo 43 del Código Disciplinario Único, que a su tenor literal preceptúa:

“Artículo 43. Criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta. Las faltas gravísimas están taxativamente señaladas en este código...”

En virtud a lo anterior, dado que la conducta endilgada al disciplinado XXXXX se ajustó a la descripción disciplinaria del numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, esto es, una falta disciplinaria gravísima, por lo que no es del caso efectuar la ponderación de los criterios orientadores que establece el artículo 43 de la misma norma. En consecuencia, la falta atribuida al disciplinado se califica como **GRAVÍSIMA**, atribuida a título de **DOLO**, tal y como fue en su momento señalado en el pliego de cargos.

8. DE LA CONTESTACIÓN DE LOS ARGUMENTOS DE DEFENSA

Respecto de los argumentos expuestos por el disciplinado se ha de reiterar que este operador, consciente del planteamiento que en su momento efectuara al cuestionar la validez de la supuesta confesión efectuada ante el comité informal que citó el Director Seccional de DIAN en Bucaramanga, reconoció la legitimidad del informe rendido en cuanto a que este documento constituyó la fuente o noticia disciplinaria con el cual se inició en forma válida la actuación respectiva, razón por la cual no resulta procedente volver a traer a colación los argumentos ya planteados al respecto.

En lo que atañe a la prueba que fuera objeto de este análisis, resulta claro que para esta argumentación, fueron tenidas en cuenta las pruebas legalmente incorporadas, siendo fuente principal el testimonio rendido en dos sesiones y bajo la gravedad del juramento, por parte del directo afectado, en este caso XXXXX, prueba que cumplió con los requerimientos de validez y que fue analizada a la luz de los preceptos de la sana crítica, además que no obstante haber servido como elemento directo de comprobación del hecho investigado, encontró apoyo en otros medios probatorios de naturaleza documental que corroboraban aspectos esenciales del relato, lo que

permitió establecer la veracidad del hecho y de la responsabilidad que se le endilgara al disciplinado desde la formulación de cargos.

Así las cosas, los testimonios rendidos por los servidores que participaron en la reunión organizada por el Director Seccional una vez conocidos los hechos, no ha constituido base esencial de la argumentación o como prueba de cargo para sustentar esta decisión o la que formuló cargos, por cuanto ha de reconocerse que fueron testimonios de oídas en lo concerniente al hecho en sí y aunque fueron practicados con el cumplimiento de las formalidades legales, no abordaron de manera directa el objeto central de la investigación, es decir la solicitud dineraria a cambio de una contraprestación ofrecida por parte del disciplinado, toda vez que no estaban presentes al momento en que la conducta se consolidó.

Con base en estos planteamientos y en consideración a que ni el investigado ni su defensor hicieron uso de la atribución de presentar alegatos de conclusión dentro del término correspondiente y que su defensa se basó en atacar algunos aspectos que ya fueron objeto de análisis inclusive desde la formulación de pliego de cargos, no considera este operador procedente entrar a realizar mayores disquisiciones a las ya plasmadas con antelación.

9. DE LA SANCION POR IMPONER

Claro como quedó en el presente proceso que el investigado XXXXX es responsable de cometer la falta disciplinaria gravísima contenida en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, con base en la configuración de los presupuestos legales exigidos por el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, al obrar en el proceso prueba acerca de la certeza de la existencia de la falta y de su responsabilidad en la comisión de la misma, es menester proceder a determinar la sanción a imponer; para lo cual se procederá, así:

La conducta por la disciplinada cometida, fue determinada sin lugar a graduación como **FALTA GRAVISIMA** realizada a título de **DOLO**; de conformidad con el artículo 44 del Código Disciplinario Único, a una conducta aní acreditada le corresponde:

***“Artículo 44. Clases de sanciones.** El servidor público está sometido a las siguientes sanciones:*

1. Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima. (...)”

Ahora bien, el término de inhabilidad general de conformidad con la misma Ley debe graduarse dentro de unos rangos de duración preestablecidos, los cuales de conformidad con el artículo 46, son:

***“Artículo 46. Límite de las sanciones.** La inhabilidad general será de diez a veinte años; (...)*”

Aclarado lo anterior, al tenor del artículo 47 de la ley disciplinaria, los siguientes son los criterios legales que guían la tasación de la sanción a imponer:

“Artículo 47. Criterios para la graduación de la sanción.

1. La cuantía de la multa y el término de duración de la suspensión e inhabilidad se fijarán de acuerdo con los siguientes criterios:

- a) Haber sido sancionado fiscal o disciplinariamente dentro de los cinco años anteriores a la comisión de la conducta que se investiga;*
- b) La diligencia y eficiencia demostrada en el desempeño del cargo o de la función;*
- c) Atribuir la responsabilidad infundadamente a un tercero;*

- d) La confesión de la falta antes de la formulación de cargos;
- e) Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado;
- f) Haber devuelto, restituido o reparado, según el caso, el bien afectado con la conducta constitutiva de la falta, siempre que la devolución, restitución o reparación no se hubieren decretado en otro proceso;
- g) El grave daño social de la conducta;
- h) La afectación a derechos fundamentales;
- i) El conocimiento de la ilicitud;
- j) Pertenecer el servidor público al nivel directivo o ejecutivo de la entidad.” (Subraya fuera del texto original).

Dentro del plenario se evidencia que al momento de la comisión de la falta el disciplinado no pertenecía al nivel directivo o ejecutivo de la entidad y que, a pesar de lo reprochable de su conducta, con ella no afectó derechos fundamentales; circunstancias que entonces deben tenerse en cuenta, a su favor.

También hay que considerar el hecho de que la conducta cometida haya contado con su conocimiento y voluntad esto es, haya sido cometida con dolo; además ha quedado establecido que el encartado era consciente de la ilicitud de su proceder, omitiendo su deber de asumir el ejercicio funcional dentro de los principios de transparencia y de moralidad públicas que le compelm a actuar de manera recta y en honor a la transparencia, postulados al cual el servidor público XXXXX, se sujetó al momento de aceptar su cargo público.

Así las cosas, siendo potestad legal del juzgador de instancia la graduación de la sanción, de conformidad con los criterios expuestos, y teniendo en cuenta que a lo largo de la instrucción no se advirtió que el comportamiento estudiado y sancionado haya producido perjuicio de carácter patrimonial al Estado, este Despacho considera que la sanción a imponer en el presente asunto al disciplinado XXXXX, será **DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL** para el ejercicio de funciones públicas por el término de **DIEZ (10) AÑOS**.

En mérito de lo expuesto, el Subdirector de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA de XXXXX, identificado con la cédula de ciudadanía número XXXXX, por la conducta consignada como cargo en el Auto número 1740600012, actuar constitutivo de falta disciplinaria al tenor de lo dispuesto en el artículo 48, numeral 1º Ley 734 de 2002.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, **IMPONER** a XXXXX, sanción disciplinaria consistente en **DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL** para el ejercicio de funciones públicas por el término de **DIEZ (10) AÑOS**, de conformidad con lo señalado en la parte motiva precedente.

TERCERO: NOTIFICAR PERSONALMENTE la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 101 y 107 de la Ley 734 de 2002, a los sujetos procesales

CUARTO: ADVERTIR que contra la presente decisión procede el **RECURSO DE APELACIÓN**.

QUINTO: En firme la presente decisión, **COMUNICARLA** en la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con el artículo 174 del Código Disciplinario Único.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE,

JORGE ADRIANO MORENO PONCE

Subdirector Técnico de Agencia Investigaciones Disciplinarias
UAE Agencia ITRC